

刘仲敬论章士钊的生平与政治角色

刘仲敬（2016 年 1 月 10 日）

他的文章，与其说是展示了他真正相信的，或者他想要读者相信他相信的东西，不如说是展示了他运用专业技术欺骗自己、说服自己的一种高超技术。

前面提到的陈炯明和阎锡山，是民国初期精英中的一个类型，就是土豪类型。他们都是成功的土豪，离不开自己的乡土，因此有严重的局限性。但他们的成就也是由他们的局限性带来的。

如果离开广东，陈炯明就不是陈炯明了。他会变成另外一个蒋介石，那么他跟广东的关系就会像蒋介石跟浙江的关系一样浮泛。阎锡山离开山西以后，也许会变成汪兆铭或者张学良那种人，山西的特殊性也就不存在了，他的土豪性质也就不复存在了。

但是民国还有另外一种人，一般来说可能更吸引聚光灯，就是我称为“游士”的那种人。游士的力量不是来自于地方共同体，他们主要依靠个人的才能，他们所希望的场地是全国性的。我们大家心目中的精英人物往往是这种人，比如梁启超、李大钊。这一类人物都是属于游士类型的人，这些名气比较大的人物可能还不是最典型，因为他们的生平过于复杂，不是特别好分析。

另外一个人物可能反而比较有代表性，就是章士钊（1881—1973）。章士钊早年的形象和我们后来留下的印象决然不同。辛亥革命初期，他是南方革命政府阵营里的，主要不是做行政工作，而是照现在的说法，是一个搞法制起草工作的人。

辛亥革命后，章士钊离开英国回国，任上海《民立报》主笔、江苏都督府顾问。民国初年是一个缔造宪法的时代。一般来说，任何人只要是对宪法制定有点方向感，都会在这方面有所发言。但是真正有专业水准的人是非常少的。其实连宋教仁和居正（1876—1951，同盟会重要成员，曾在日本大学学法律。辛亥革命后参与筹组湖北军政府和制定都督府暂行组织条例，南京临时政府成立后任内政部次长，参与《中华民国临时约法》的制定）都算不上是真正专业的。他们是业余爱好者中水准比较高、而责任心和敏感性比较强的人。从法律技术角度来讲，真正的专家不算太多，而章士钊恰好是其中之一（1908 年入英国阿伯丁大学，学法律、政治，兼攻逻辑学）。

民国初年，那些人有点像 80 年代的启蒙运动：热情有余而专业技术不足，方向感很强，但是具体工作总是疏漏过多。有一件事情就可以证明：他们当时是中国近代史上最积极引用共和主义和宪政主义的人，但他们也采取了一个很荒谬的措施，就是在中国设立行政法院，理由是欧洲大多数国家都有行政法院。这时，章士钊就写了一篇文章，论证设立行政法院非但不是保障法治，而恰好是破坏法治的。因为宪法之母英国就不设行政法院。

行政法院在技术上有千头万绪，但政治上的精神是很明显的，它就是要给官吏以特殊的保护，不由普通陪审团审判，而是交给特殊的行政法院审判。行政法院的意义不仅仅是制定特殊的行政法律，而是要能够随时随地体谅到“国家的理由”。如果官吏很容易因为“国家的理由”而受到审判，像普通的被告人一样自己付出代价的话，那么对政令畅通是有极大危害的。

我想现在的公务员都很清楚（我当过，所以我知道），如果你做了什么事情跟老百姓起了纠纷，最后告到上级领导，结果往往是息事宁人。到底这件事情谁对谁错是次要的问题，因为纠缠起来太浪费时间，造成的损失比分清谁对谁错还要大。往往就是由政府拿一笔钱给那个闹事的老百姓，给他们各种各样的好处，息事宁人，只要能不闹事、不来纠缠我们就行。你说是对的，那就是对的。

这种情况，如果按照英美那种法律体系，那么这个负责办事的公务员就得自己出钱请律师，自己卖房子，请个律师去跟老百姓打官司。如果那个老百姓要纠缠你，连续打 10 年官司，你就倾家荡产陪他打官司去吧。如果打输了，该坐牢你自己去坐牢，跟你上级机关没有关系。换句话说，上级机关不能保护你。

我想如果按照中国现在这种国情，实行了刚才所描绘的那种英美的制度，基本上可以断定，任何没有背景的公务员，唯一敢做的事情就是在办公室里面喝茶看报。

欧洲大陆法系的国家，其社会生态多多少少是比较接近于中国这种情况的。它设立行政法院，就是为了避免我们刚才所说的那种情况的出现。如果出现民告

官的诉讼，由一个特殊的行政法院去处理。这个法院会充分考虑到公务员办事的难处，不能打击公务员办事的积极性。

因为，立宪国家的特点，像斯密所谓的“立法国”，就是欧洲大陆那种具有强大行政体系的国家。国家和行政机关差不多就是一回事。如果公务员不敢办事，那么国家其实就不存在了。即使公务员做的是错的，你也不能随便打击他的积极性。当然，人权也是要保护的。

行政法院的作用就是：一方面，在具体的利益方面保护普通老百姓的人权；另一方面，注意不伤害公务员办事的积极性，要随时注意“国家的理由”和政令畅通。这些事情，普通法的陪审员是不会照顾到的。英美的陪审团经常会让政府的公务员、警察之类的人赔几百万美元、坐很多年的牢，大家都是置若罔闻的。

但是，英美这样做的原因很简单：就是打官司的这些公务员都是地方系统的。他们要么是某个市选举出来的政府官员，或者是其他自治团体聘任的官员。那些自治团体的地位其实跟一般的公司差别不大，不会说少了你一个就影响政令畅通。再说，它也没有“政令畅通”这回事，白宫根本就不需要在地方上搞什么政令畅通。

所以，在他那种体制下，行政法院是不必要的，是对宪法的一个损害，是多余和碍事的东西。

章士钊能写出这一点，我想，那些人设计行政法院的时候，其实他们心里面可能还觉得是在模仿西方宪政先进国家。他们根本分不清楚大陆法系国家和海洋

法系国家在政情、国情、民情和司法体制上的相关性，就是闭着眼睛觉得西方好的大概就是好的。我们象征性地模仿一下，好在哪里，坏在哪里，也只是粗枝大叶地有个模模糊糊的了解，大体上觉得西方先进，引进先进理念应该没错。具体的内容，比如立法的科学性、不同的法律应该怎样相互适应、应当怎样和社会环境相互适应，这方面他们是不清楚的。而从章士钊反驳他们的文章就可以看出来。

第二，章士钊在这方面是非常清楚的。他有做一个英国律师的良好才能。他在这时期，因为他还没有负实际的政治责任，写这样的文章是相当多的。现在人把它忽略掉，实在是有点可惜。因为跟他比较起来，宋教仁就算不上什么了。宋教仁是宪法制定者，也许是个好的宪法制定者，也许是个坏的宪法制定者，但是宋教仁不是一个好的立法者，他是一个非常粗枝大叶的人。国民党里面绝大部分都是宋教仁这样的业余爱好者，真正专业的人他们反而不太重视。

章士钊就是这样一个专业人员。后来他跑到北洋政府里面去，可能也是出于偶然。北洋政府的技术官僚精神比国民党要强得多。

后来国民党取代北洋，和共产党取代国民党，从技术官僚的角度来看，都属于是倒退性质的。等于是把已经好不容易学了半天、交了很多学费打下的一点基础推倒了，又在白地上让一帮粗人从头学起，再交一批学费从头搞起来。这种事情在中国近代史上是一再发生的。在政治上好像是进步的东西，但是从管理技术、立法技术上转了一圈，实际上是破坏性和倒退性的，因此反攻从头做起是一而再、再而三的。

章士钊在北洋那一边得到重用，1924 年任段祺瑞执政府司法总长，1925 年兼教育总长，1926 年任职政府秘书长，主要就是靠他在行政技术方面的能力。但是他也付出了重大的牺牲。他真正的才干实际上是对英美法系的了解，但是北洋政府是不需要那一套东西的，那套东西对北洋政府的吏治是有极大的伤害。

就民国初年的权力结构来说的话，谈论英美法系那些原则，原则上谈起来很好，但实际上执行起来主要是捆住了政府的手脚。捆住了政府的手脚，就间接地有利于暴民运动。而国民党在当时是暴民运动的主要代表，所以国民党往往以投机性的方式来支持英美法系，或者是泛泛而谈地指责北洋政府搞的这些不行，大陆法系实在太烂等等。但是实际上他们也根本不是什么英美法系的爱好者，他们只是想拆台而已，就是想拆北洋政府的台。

章士钊在这些游戏中扮演了一个很矛盾的角色。照他自己的学历出身，他最擅长的事情实际上是他不能做的事情。他恰好是以一种扭曲的方式在维护北洋政府的吏治国家，是北洋法政系官僚集团的一个活跃分子和干练的精英，为北洋政府培养出了很高效的行政集团。但这个行政集团并没有遵守他在民国初年所鼓吹的那些现代原理。

在这段时间里，他与其说是英美宪法的传播者，不如说是明治绝对主义国家的一个复制者。对于北洋政府来说，真正好用方便、能够在短期内生效的东西，恰好就是明治国家那里已经很成熟的那些东西。

后来，章士钊之所以会跟那些学潮扯上关系，也是因为他引进了日本的学制。日本的学制在这方面的原型，跟他们的欧洲模范不一样，也跟他们在古代的中国模范相距甚远。

因为中国古代的儒家教育和欧洲中世纪乃至近代以来的自由教育，虽然有很多不同，但有一点是相当相似的，就是他们比较看重民间自治团体。有很多书院都是民间自治团体办的，有独立的财源。官府往往给资助，但是即使官府没有资助，他们仍然有一定的筹款能力，仍然有自我维持的组织系统。欧洲的学院就是一个独立的法人团体，是根据特许状建立的法人团体。从性质上来讲，侵犯大学的行为……

像詹姆斯二世国王（信奉天主教的詹姆斯二世）曾企图将天主教士硬塞进牛津大学担任莫德林学院院长，这遭到了坚决抵制。那是一种违宪行动，侵犯牛津大学与侵犯伦敦市一样，都是对宪法的侵犯，这是毫无疑问的。

但是，日本明治国家没有采取这种体制，它采取的是一种“以吏为师”的体制。明治时代建立的学校由文部省负责管理，其自治能力比起真正的西方大学和中国古代的书院来说，下降了不少。学校的管理人员是按照公务员序列安排的。

章士钊想要引进的就是这种日本体制。他认为这种体制在日本运行得很好，而且精神十足。他觉得主要是体制的原因：只要搞出一种上下令行禁止的体制，就能够改变那些散漫、闹学潮的现象，就可以复制出类似日本那种严谨的、带军国主义色彩的新精神。

当然，从后世的角度看，日本之所以有那种精神，还是因为日本有特殊环境的缘故。中国不一定能够复制这种特殊环境，但是无论如何，章士钊还是这么做了。他这种做法，是他跟北洋政府能够情投意合的主要原因。

但是，技术官僚自有技术官僚的悲哀。就是说，不管你是多么能干，你的行政能力和政治能力是两码事。行政上的干才，在政治上往往是白痴和受人利用的。章士钊手下的那批人，就包括像李大钊和鲁迅。

这批人眼里好像是呼风唤雨的人物，但在北洋政府中间，他只是一个受人摆布的小角色。只要他的保护人倒台了，那么他的一切苦心经营都要付诸东流。

随着段祺瑞政府的倒台，章士钊实际上就已经落到中下层。他的后半辈子在上海当律师，表面上是当律师，实际上是在做政治掮客。因为中国士大夫特别有一种现象，就是说你一旦尝过了权力的滋味，就好像是老虎见着血，你再也不可能回到原来专业人士的轨道上去了。不是技术上不可能了，而是心理结构上不允許了。其实你明明知道你的黄金时代已经过去，但是你总是舍不得这种滋味，总是要奔走于各派权势之门，希望能够重新找回自己的地位。

章士钊后半辈子就是这样子的。他当律师，给陈独秀写辩护词，给其他人辩护，其实都是政治掮客活动的一部分。它真正的作用是在各派势力之间拉纤，起传递信息、充当交易媒介的作用。说得刻薄一点，它有点像是法国的沙龙，或者旧国会时代八大胡同的主持人那种人，他给你提供一个信息交流场的作用，而不

是自身有很大的势力。而且，随着党国体制日益趋向恐怖，他这个交流场的空间正在逐渐地缩小。

在同时还操着律师职业的情况下，他有时候还写一些文章。如果你孤立地看他那些文章的话，好像会觉得他是不是又回到了早年那种鼓吹英美宪政的路上；或者看另一些文章，觉得他好像又沾染了苏俄革命以后的激进主义和社会主义色彩。

其实这都不对。这些文章都是投机性的，跟他当时在掮客界的临时性措施有很大关系。临时性措施都是很短命的，用完了就扔，然后他就要换一种新的立场。在他一生最后的阶段，立场变成了一个不值钱的，而且越来越不值钱的东西。

它就像是一条大鱼一样，曾经在很深的水里面游泳，但是出于他自己无法控制的原因，水越来越浅，他这条鱼慢慢就要被晒成鱼干了。他一生中的最后几年，就是在晒成鱼干的过程中，力图通过适应咸鱼干的生活来改造自己的意识。这种改造也是相当痛苦、相当扭曲的过程。

从这个角度来讲，尽管他是一个很狡猾、很会投机，而且差不多每一次投机都能投到正确地方的角色，但他的生活仍然是相当痛苦的。尤其是这个样子：你只要选择了这个生活方式，那就等于说你必须歪曲自己去迁就你的环境。

在这个方面来说，章士钊是一个典型。他的文章可读性从早年到晚年是不断减退的，而且减退的方法非常狡诈，因为他的专业能力始终是很强的，甚至可能

晚年比早年更强。他不断地用他的专业能力去扭曲他的论点，把本来是自相矛盾的东西粘接在一起。他一生中唯一一个逻辑连贯的阶段就是 1912 年到 1918 年阶段。在这以后，他的文章老实说，如果不了解他的思想背景的话，最好不要相信他的文章。

因为他的文章与其说是展示了他真正相信的，或者他想要读者相信他相信的东西，不如说是展示了他运用专业技术欺骗自己、说服自己的一种高超技术。这种技术可以说在 20 年代后期是个转折点，在中国知识界中变得越来越流行。流行到一定程度就会物极必反，使整个知识体系的复杂化、精细化变得毫无意义，让你觉得干脆根本取消掉这个交流场，用更加简单、更加低成本的方式进行信息交流，反而是有利可图的。

从这个角度来讲，章士钊和章士钊所代表的这个巨大的群体，是在完成一种阶级自杀的行为。他是其中之一，但他不是唯一一个。另外一个人就是李大钊，以不同的方式完成了同样的实例。

注释一：在辛亥革命前夕，章士钊发表《无国设立行政审判院，在宪法上当作合意位乎？——行政审判论》一文指出：

“法兰西人以为政府与政府之官吏实为国民之代表，以享有一种特权，为私人所不有者。而规定此种特权之原理，与所规定人民普通权利义务者当有不同。法人所谓分权，自以为得之于英伦，是乃其谬。盖英人所持乃法律平等主义，自总理大臣以至乞丐，一律受审判于普通法庭，法律之眼光从不等差国家之分子而

歧视之，其理想与法人本质以编制刑法者，如冰炭之不相得。行政法之原则，基于国家代表之应有特权。”

凡此种代表，以其公人资格有所行动，其行动非寻常法庭所能问。私人与之有所交涉，其地位与私人相互交涉时，所立者迥然不同，官吏所受之处分与私人所受者又截然有异。若而薄者，官吏与人民之间有一鸿沟，官吏所享之特权非人民所能有，而人民原有宪法上之权利，亦与官吏之特权相冲突，而其动摇者称为特权法治之国。此种法治，是在英美法家之所不解，应为宪政母国英与其他操英语国成器流风，皆不赖行政法而治，真上理也。在欧陆诸国采用行政法者，其行政司法两部之间没有隔阂，其结果乃至司法不能独立，致宪法失其作用。

1912年3月11日，南京政府临时参议院公布《临时约法》。章士钊于3月12日写出《临时约法与人民自由权》，批评道：“约法曰：‘人民之身体，非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚。’倘有人不依法律逮捕、拘禁、审问、处罚人民则如之何？以此质之，曰法曰法，不能答也。”章士钊认为，这是许多成文宪法的共同缺陷，应该吸取英美法系的优点而加以补救。“无论何时，有违法侵害人身之事件发生，无论何人或本人或其友，皆得向相当之法庭呈请出庭状，法庭不得不诺，不诺则予以相当之罚是也。出庭状者，乃法庭所发之命令状，命令侵害者于一定期限内率被害者出庭，陈述理由，并受审判。”

此部分亦针对《临时约法》第十条所规定的“人民对于官吏违法损害权利之行为，有陈诉于平政院之权”。章士钊主张应删除这一条。“平政院者，即行政裁判所之别词也。凡有平政院之国，出庭状之效力必不大。何也？人民与行政官有

交涉者，乃不能托庇于普通法庭也。使行政权侵入司法权，则约法所予人民之自由者，殆所谓猫口之鼠之自由矣。”

1925 年 4 月，章士钊兼署教育总长，下决心从三件事抓起：

1. 宣布大学统一考试，教育部专设考试委员会，主抓学生的入学、毕业考试。
2. 教育部设编译馆，督促奖励各大学教授著书、译书。
3. 合并北京八所大学。

但其主张遭到进步人士和青年学生的强烈抵制，根本无法实施。5 月 7 日，章士钊自己的住宅也被学生捣毁。5 月 12 日，章士钊辞去本兼各职，经段祺瑞婉劝，才重就司法总长职。

7 月 28 日，段祺瑞专调章士钊出任教育总长，意图整顿教育，抑制学潮。此前，北京女子师范大学驱逐校长杨荫榆的运动已愈演愈烈。在章士钊的支持下，杨荫榆宣布开除刘和珍、许广平等 6 名学生。8 月 6 日，章士钊在国务会议上提请停办女师大，当即通过。消息传出，女师大学生拒绝解散令，在报纸上号召驱章，并组织校务维持委员会维持校务，周树人为总务主任。在此期间，周树人以“鲁迅”笔名写下《流言和谎言》等文，支持女子师大学生，抨击章、杨。

8 月 12 日，章士钊据文呈请免去周树人的教育部佥事一职。8 月 14 日免职令发表。但周树人所任的佥事一职属于荐任官，如要惩戒，需由主管上级备文申述事由，经高等文官惩戒委员会会议审查后使得实行，章士钊并未办理这一手续。

周树人抓住这一点，于 8 月 22 日向专管行政诉讼的平政院提交了诉状。平政院于 1926 年 2 月 23 日作出裁决，判定周树人胜诉，恢复职务。

1932 年 10 月 16 日，陈独秀在上海被捕，章士钊出任义务辩护律师。他对法庭说：“起诉书所引罪名，一则曰‘叛国’，再则曰‘危害民国’。窃思国家作何解释，应为法院之所熟知。国家与主持国家之机关（或政府）及人物，既截然不同范畴，因而攻击机关或人物之言论，遽断为危及国家，于逻辑无取，于法理不当。以言论反对或攻击政府，无论何国，均不为罪。”